

<입문-제2장 행정입법(법규명령·행정규칙).제3절 행정규칙의 형식과 내용>

I. 법규명령 형식의 행정규칙

1. 문제의 소재

- 법규명령 형식의 행정규칙이란 형식은 대통령령, 부령 등 법규명령의 형태를 취하고 있지만, 그 내용은 국민의 권리·의무에 관한 사항이 아닌 행정조직 내부의 사무처리 기준이나 재량권 행사 준칙만을 규율하는 경우를 말한다. 원칙적으로 법규명령은 대외적 구속력을 가져야 하지만, 이러한 경우 내용상으로는 법규성이 없는 행정규칙의 성질을 가지므로 그 법적 효력을 어떻게 볼 것인지에 대한 견해의 대립이 발생한다. 특히, 해당 규정이 국민에게 간접적으로라도 영향을 미칠 때, 이를 법규명령으로 보아 위헌·위법 심사의 대상으로 삼아야 하는지 여부가 핵심 문제이다.

2. 학설

(1) 행정규칙설

- 규율 내용이 법규 사항(국민의 권리·의무)이 아닌 행정조직 내부의 사무처리 기준이나 재량 준칙에 불과하므로, 그 형식이 법규명령이라 하더라도 실질적으로는 행정규칙에 해당한다는 견해이다. 따라서 대외적 구속력을 부정하며, 법원의 직접적인 심사 대상이 되지 않는다고 본다. 이 견해는 법규명령의 실질적 의미를 중요시한다.

(2) 법규명령설

- 대통령령, 부령 등 법규명령의 형식으로 제정된 이상, 국민의 대표 기관인 국회의 위임을 받아 법규명령으로 제정된 것이므로 행정조직 내부만을 규율하는 내용이라 할지라도 법적 안정성과 권력 분립 원칙상 법규명령으로 보아야 한다는 견해이다. 다만, 그 내용이 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미치지 않아 재량 준칙의 성격을 가진다면, 대외적 구속력은 인정하지 않거나 제한적으로 인정하는 입장이 병존한다.

(3) 절충설

- 법규명령의 형식을 취한 이상, 행정조직 내부에서는 법규명령으로서 효력을 가지고, 외부 관계에서는 재량 준칙으로서 행정규칙의 성질을 가진다고 보는 견해이다. 법적 안정성과 실질적인 규율 내용을 모두 고려하여 절충적으로 해결하고자 한다.

3. 판례

- 판례는 대통령령에 규정된 경우에는 법규명령으로, 부령에 규정된 경우에는 행정규칙으로 본다.

(1) 대통령령 형식인 경우

- 판례는 제재적 처분기준이 대통령령의 형식으로 정해진 경우 당해 처분 기준을 법규명령으로 본다.

(2) 부령 형식인 경우

- 원칙은 행정규칙으로 보나, 예외적으로 법규명령으로 본 판례(대법원 2006.6.27. 2003두4355-부령 형식으로 본 특허의 인가기준)와 법령(도로교통법 시행규칙 제97조-운전면허의 취소·정지 처분 기준 등)이 있다.

II. 행정규칙 형식의 법규명령(법령보충규칙, 법령보충적 행정규칙)

1. 문제의 소재

- 행정규칙 형식의 법규명령이란 훈령, 예규, 고시 등 행정규칙의 형식으로 제정되었으나, 법률이나 상위 법규명령의 구체적인 위임을 받아 국민의 권리·의무에 관한 사항을 보충적으로 규정하는 경우를 말한다. 원칙적으로 행정규칙은 대외적 구속력이 없어야 하지만, 법규 사항을 규정하고 있으므로 그 법적 성질과 효력을 행정규칙으로 보아야 할지 법규명령으로 보아야 할지가 핵심 문제이다. 특히, 이러한 규칙이 국민의 권리를 제한하는 경우, 법률유보의 원칙을 준수했는지 여부가 중요하게 다루어진다.

2. 학설

(1) 행정규칙설

- 법규명령은 대통령령, 부령 등 법규명령의 형식으로만 제정되어야 한다는 형식주의에 입각하여, 고시 등 행정규칙의 형식을 취한 이상 내용이 법규 사항이라 하더라도 행정규칙에 불과하다는 견해이다. 이 견해는 법규명령의 형식적 안정성을 중요시하며, 국민의 권리 제한은 법규명령의 형식으로 이루어져야 한다고 본다.

(2) 법규명령설(법령보충규칙설)

- 법률이나 상위 명령이 구체적으로 위임한 사항을 보충하는 내용이라면, 그 형식이 행정규칙(고시 등)이라 하더라도 상위 법령과 결합하여 대외적인 법규로서의 효력을 가진다는 견해이다. 이는 법규명칙주의(실질적 법치주의)에 입각하여 실질적인 규율 내용과 상위 법령과의 연결 관계를 중요시하며, 판례가 취하는 통설적 입장이다.

(3) 독자적 효력 부정설

- 행정규칙 형식으로 제정된 내용은 상위 법령의 위임 범위 내에서만 상위 법령과 합체하여 대외적 효력을 가진다고 본다. 즉, 행정규칙 자체가 독자적인 법규로서의 효력을 가지는 것이 아니라, 상위 법령의 효력에 의존하여 법규명령과 같은 기능을 수행한다고 본다.

3. 판례

- 판례는 법령보충적 행정규칙에 대해 법규명령설의 입장을 취하며, 그 대외적 구속력을 인정한다.

(1) 법규명령성 인정 기준

- 판례는 고시, 훈령 등 행정규칙의 형식을 취하고 있더라도, 상위 법령(법률, 명령)이 구체적으로 위임한 사항을 정하고 있다면, 그 고시 등은 상위 법령과 결합하여 대외적인 법규로서의 효력을 가진다고 본다. 이 경우, 고시 등은 상위 법령을 보충하는 기능을 수행하며, 국민의 권리·의무를 규율하는 법원(法源)이 된다.

(2) 법률유보의 원칙 적용

- 법령보충규칙이 법규명령의 효력을 가지기 위해서는 법률유보의 원칙이 적용되어야 한다. 즉, 상위 법령의 구체적이고 개별적인 위임이 있어야 하며, 고시 등의 규율 내용이 상위 법령의 위임 범위를 벗어나 새로운 규제를 창설하거나 위임의 근본 취지에 반해서는 안 된다. 위임 한계를 벗어난 부분은 무효로 판단된다.

(3) 처분성 인정 여부

- 법령보충규칙은 상위 법령과 결합하여 대외적 구속력을 가지지만, 일반적·추상적인 규율의 성격을 가지므로 원칙적으로는 행정 처분에 해당하지 않는다. 그러나 행정청이 이 규칙에 근거하여 구체적인 집행 행위(처분)를 한 경우, 행정 처분의 위법성은 상위 법령과 결합된 법령보충규칙의 위법 여부를 기준으로 심사된다.

III. 결론

- 법규명령 형식의 행정규칙과 행정규칙 형식의 법규명령(법령보충규칙)은 행정입법의 형식과 내용이 불일치하여 발생하는 법적 효력에 관한 중요한 쟁점이다. 판례는 법적 안정성과 법률유보의 원칙을 모두 고려하여, 전자의 경우는 형식을 존중하여 법규명령성을 인정(대통령령, 부령 일부)하고, 후자의 경우는 상위 법령과의 결합을 통해 실질적인 내용을 존중하여 법규명령의 효력을 인정한다. 특히 법령보충규칙은 상위 법령의 구체적 위임이 한계가 되며, 이 한계를 벗어난 경우 무효가 되어 법치 행정의 원리에 따른 사법 통제를 받는다.